

1500060-36.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... tal", o "indivíduo tal" faria o tráfico. Disse que desembarcaram antes e ficaram observando da esquina. Informou que observaram que no local movimentação típica de tráfico de entorpecentes e que tentaram efetuar a abordagem e que o usuário se evadiu. Acrescentou que explicaram o teor da denúncia ao réu, que admitiu estar praticando o tráfico para complementar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500060-36.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500060-36.2022.8.26.0580

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudemir Borges da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de CLAUDEMIR BORGES DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Narrou, na inicial acusatória, que, em 22 de janeiro de 2022, por volta de 19h20min, na Rua Salvador Ricci, nº 44, Golden Park, nesta cidade e comarca de Palmital, o denunciado guardava e tinha em depósito para entrega e consumo de terceiros, 4 (quatro) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 163,27g, e 34 (trinta e quatro) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 10,95g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acrescentou que, nas proximidades do local em que o imputado realizava o tráfico de drogas, havia duas unidades escolares ("Escola Fundamental Ver. Miguel Bueno Vidal" e "Escola Municipal Anna Beatriz Ortega Monteiro"), o que lhe proporcionava maior facilidade na disseminação da droga

O réu foi notificado (fl. 144) e ofereceu defesa prévia (fls. 151/154).

A denúncia foi recebida em 22/03/2022 (fls. 155/156).

O réu foi citado (fl. 180)

Na fase instrutória, foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 202/205 e 245/248).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência do pedido formulado na denúncia. Requeru ainda: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III,

da Lei n. 11.343/06; c) fixação de regime inicial fechado (fls. 253/257).

A Defesa, por sua vez, sustentou, em síntese, que a) deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, substituindo-se a pena por penas restritivas de direitos; b) a pena deve ser fixada no mínimo legal; c) deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea; d) deve ser afastada a causa de aumento descrita na denúncia; e) deve ser concedida a justiça gratuita e aplicado o perdão da pena de multa (fls. 258/266).

É o relatório. Decido.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas ou a presença de nulidade que deva ser conhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, dos termos de depoimentos de fls. 03/04, do boletim de ocorrência de fls. 31/34, do auto de exibição/apreensão de fls. 35/36, do laudo de constatação de fls. 53/55, do exame químico-toxicológico definitivo de fls. 122/124 e das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, por seu turno, foi comprovada por meio da prova oral produzida nos autos.

Nesse diapasão, a testemunha Leonardo Moreno Marques, policial militar, disse que participou da ocorrência. Afirmou que estavam em patrulhamento em Palmital e receberam denúncias de pessoas que não querem se identificar por medo de represálias, mencionando que na casa de “número tal”, o “indivíduo tal” faria o tráfico. Disse que desembarcaram antes e ficaram observando da esquina. Informou que observaram que no local movimentação típica de tráfico de entorpecentes e que tentaram efetuar a abordagem e que o usuário se evadiu. Acrescentou que explicaram o teor da denúncia ao réu, que admitiu estar praticando o tráfico para complementar a renda mensal. Informou que ele autorizou a entrada e mostrou na residência potes com maconha e cocaína. Afirmou que encontraram dinheiro também. Esclareceu que a pessoa que eles indicaram era o réu Claudemir. Confirmou que foram às proximidades do local indicado na denúncia. Afirmou que era o réu que estava entregando o objeto e que estavam cerca de vinte, trinta metros. Relatou que a movimentação era na calçada. Afirmou que o réu foi abordado próximo do portão, quase ingressando na residência. Acrescentou que na residência não havia mais ninguém e que, posteriormente, chegou mulher que se identificou como namorada ou amásia do réu e a mãe dele. Relatou que elas chegaram depois. Afirmou que não se recorda de terem chamado o canil para realizar varredura. Acrescentou que se recorda que nesse caso em específico, o réu foi denunciado de modo exato, com indicação do nome e do seu endereço. Indagado se a rua fica em frente de escolas, afirmou que não se recorda e que é perto da escola Tobias Aguiar. Afirmou que não se recorda se a “Escola Fundamental Ver. Miguel Bueno Vidal” e a “Escola Municipal Anna Beatriz Ortega Monteiro” ficam nas proximidades. Indagado sobre a menção à movimentação típica de tráfico, esclareceu que encostou um indivíduo de bicicleta e que aparentemente um entregou objeto para o outro e que o indivíduo com a bicicleta conseguiu se evadir. Informou que não foi possível visualizar os objetos. Afirmou que não se recorda onde o dinheiro foi encontrado, mas que o réu admitiu ser proveniente do tráfico. A testemunha Everson Claro da Costa, policial militar, disse que se recorda da ocorrência. Afirmou que, no dia, estavam em patrulhamento por Palmital, quando receberam informação que detalhava, com riqueza de detalhes, o local e a pessoa que estava realizando o tráfico. Disse que foram para próximo da casa e observaram a casa para ver se realmente ocorria. Informou que viram pessoa sair no portão e contato com pessoa de bicicleta, sendo nítida a troca e o recebimento de dinheiro. Afirmou que abordaram o réu na entrada da casa e, em busca pessoal, localizaram eppendorf de cocaína e dinheiro. Relatou que o réu admitiu ter em depósito mais drogas para a venda. Afirmou que ele disse estar passando por problemas financeiros. Disse que pediram autorização para entrar na residência, a qual foi dada por escrito. Disse que, em potes, havia cocaína e maconha. Relatou que foi dada voz de prisão e o réu foi conduzido à delegacia. Disse que anteriormente não tinha notícia do envolvimento do réu no tráfico de drogas. Mencionou que para o depoente não havia notícias de tráfico no local. Relatou que não conhecia o acusado e que ele não estava sob efeito aparente de álcool ou drogas. Disse que não

foram encontrados apetrechos para o uso nem material para o embalamento para o comércio. Relatou que o réu não lhe relatou há quanto tempo estaria praticando o tráfico. Disse que há escola próxima, que fica cerca de 100, 150 metros do local. A informante Jucélia Aparecida dos Santos afirmou que sabe que o réu estava passando por situação, com a esposa dele grávida. Disse que ele trabalhava como diarista, mas que era período de chuva. Informou que ele estava com aluguel atrasado. Mencionou que ele trabalhava em roça, carpindo e como servente de pedreiro. Afirmou que não teve notícia do envolvimento dele com tráfico de drogas, apenas dessa vez. Relatou que mora próximo e que viu os policiais batendo, ele abriu e que viu os policiais entrando. Disse que ele assumiu o erro e deixou os policiais entrarem. Afirmou que o réu trabalhava na Cocamar, mas foi dispensado. Disse que há dois ou três meses que ele estava desempregado.

Na fase de inquérito, o acusado exerceu seu direito ao silêncio (fl. 06).

Judicialmente, ao ser interrogado, o réu afirmou que as drogas não eram suas. Disse que aceitou guardar as drogas por estar desempregado e que estava difícil, em razão da pandemia. Informou que aceitou guardar e que recebeu dinheiro. Relatou que pegou as drogas cedo para devolver a noite, mas que não deu tempo. Informou que foi atrás de serviço. Disse que iria receber R\$150,00. Relatou que não pode falar o nome de quem iria lhe pagar. Disse que não vendeu e que foi um erro que cometeu. Afirmou que não estava trabalhando. Relatou que as escolas ficam longe de sua residência. Mencionou que estava passando por dificuldade financeira, com sua esposa grávida. Relatou que sempre trabalhou quando teve oportunidade. Disse que aceitou guardar a droga por impulso, pois estava sem rumo na vida. Relatou que foi atrás de emprego e que havia conseguido. Afirmou que queria retomar sua vida. Disse que estava fazendo bicos na granja São Luís na época dos fatos. Mencionou que, quando não trabalhava, ficava difícil. Relatou que sua família lhe ajudava. Mencionou que sua casa era alugada.

O quadro probatório delineado acima permite a formação de juízo de convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva, haja vista a comprovação de que o acusado guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de modo coerente, que receberam notícia a respeito da prática do crime de tráfico de drogas pelo réu no endereço indicado na exordial acusatória, bem como descreveram que foram ao local e que visualizaram possível venda de entorpecentes, acrescentando ainda que o réu teria admitido a prática delitiva e permitido o ingresso dos policiais na residência, local onde foram encontradas as substâncias constantes do auto de fls. 35/36, bem como valor em espécie na posse do denunciado.

Ressalta-se que, na situação dos autos, as palavras dos policiais militares apresentam confiabilidade, porquanto não foram trazidos dados verossímeis que pudessem desaboná-las e não se vislumbra que teriam qualquer motivo para prejudicar o réu.

Sobre o tema, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese"(AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

O C. Supremo Tribunal Federal também já asseverou que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC 73518, Relator(a): CELSO

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)

Não se vislumbra, outrossim, irregularidade no ingresso no domicílio por parte dos policiais militares, haja vista o termo subscrito pelo acusado e juntado à fl. 37, bem como ante a ausência de fundamentos concretos e idôneos a afastar a autorização constante na referida declaração ou a indicar qualquer vício de consentimento em sua lavratura.

Deve-se acrescentar que a variedade de drogas apreendidas, a existência de notícia prévia sobre o cometimento do crime pelo réu no endereço objeto da ação policial, a visualização pelos policiais de possível ato de venda de drogas e a admissão do tráfico pelo acusado permitem concluir, de modo cabal, que as drogas se destinavam ao comércio espúrio.

Observa-se, ademais, que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

Frisa-se ainda a impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, porquanto os elementos probatórios produzidos indicam a mercancia espúria, consoante detalhado alhures, inexistindo, noutra banda, substrato mínimo a indicar que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal.

A prova produzida não deixa dúvidas, portanto, de que o acusado praticou a infração penal descrita na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Reconhece-se, noutro giro, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, ante o seu caráter objetivo e ao fato de o relatório de fls. 126/127 evidenciar que a conduta fora praticada nas proximidades de duas unidades escolares.

Sobre o tema, c. Superior Tribunal de Justiça tem exposto que:

"1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ademais, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica - como efetivamente tinha, no presente caso, ao que se colhe do acórdão (e-STJ, fl. 1.157). Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)." (AgRg no REsp 1929375/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Verifica-se também a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois a certidão de fls. 60/61 indica a primariedade do acusado e inexistem elementos indicativos de que o acusado integre organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, já que o mero cometimento de ação descrita no núcleo do tipo penal em questão não se mostra suficiente para afastar a aplicação da minorante em tela, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em caso quejando:

"1. Revela-se ilegal a não aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 à condenada primária e sem antecedentes criminais surpreendida na posse de pequena quantidade de entorpecentes - 4 gramas de crack e 46 gramas de maconha - quando a Corte a quo, com base na conduta criminosa que lhe foi atribuída e pela qual findou condenada, concluiu que fizesse da traficância sua profissão, sob pena de considerar toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 uma situação incompatível com a aplicação da minorante em questão." (PExt no HC 253.732/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/11/2013) .

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática da conduta acima

delineada, razão pela qual passo à dosimetria das penas, em atenção ao previsto no art.68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase do cálculo da sanção penal, verifica-se que as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no piso legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Esclarece-se que as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 serão apreciadas na terceira fase de dosimetria, como forma de se evitar a consideração das mesmas circunstâncias em duplicidade, conforme tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 712):

"As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena." (ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)

No mesmo sentido, pronunciou-se o c. Superior Tribunal de Justiça:

"1. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos - 'expressiva quantidade de drogas' - na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado." (EDcl no HC 648.275/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, não obstante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), por a pena já se encontrar no mínimo legal, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, mantenho a reprimenda no patamar acima citado.

Na última fase, apesar de a infração ter sido cometida nas imediações de duas unidades escolares, tendo em vista que não houve a demonstração da efetiva disseminação da droga em tais locais, aumento a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razão da incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, bem como em face do especial poder lesivo de uma das substâncias apreendidas (cocaína), aplico a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no patamar de 1/2 (metade), de modo que a pena fica definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Lei n. 11.343/06, art. 43), devido à ausência de maiores apurações sobre a situação financeira do acusado.

Quanto a esse aspecto, afasta-se o requerimento defensivo de dispensa do pagamento da pena pecuniária, visto que eventuais questões referentes à possibilidade de cumprimento da sanção pecuniária devem ser formuladas perante o Juízo das Execuções, nos termos do art. 168 e seguintes da Lei de Execução Penal.

Estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a primariedade do acusado, as circunstâncias judiciais acima descritas e a quantidade de pena fixada, bem como o entendimento consolidado pelo c. Supremo Tribunal Federal (Tema 972) de que:

" 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." (ARE 1052700 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, §2º), consistentes em (i) prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública a ser definida na fase de execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e (ii) pagamento de prestação pecuniária, prevista no artigo 43, inciso I, do Código Penal, a qual fixo, considerando a condição financeira do acusado, em 01

(um) salário mínimo, em favor de entidade a ser designada na fase executória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu CLAUDEMIR BORGES DA SILVA, como incurso no art. 33, caput e §4º, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública a ser definida na fase de execução e pagamento de prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos acima delineados, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o regime inicial acima fixado para o início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a manutenção da prisão preventiva do acusado consistiria em medida desproporcional, uma vez que mais gravosa do que a reprimenda fixada na sentença. Por essa razão, revogo a prisão preventiva do acusado e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o respectivo alvará de soltura para que o acusado seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, esclareço que deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois se trata de crime de perigo abstrato, inexistindo vítima determinada.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o requerimento de concessão da gratuidade da justiça ser examinado na fase de execução, dada a possibilidade alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1840436/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020; AgRg no REsp 1857040/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

Proceda-se, em relação à droga apreendida, conforme determinado no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos dos artigos 63 da Lei n. 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Palmital, 30 de maio de 2022.

JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA